

1506162-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do porte para consumo diz respeito à inibição ao tráfico de drogas pela lógica de que o consumo alimenta o tráfico, o que se prestaria a proteger a saúde pública. Sobre esse argumento, o Professor Pierpaolo Cruz Bottini esclarece que "é preciso notar que o pragmatismo da eficácia não pode levar à restrição da liberdade do cidadão para combater comportamentos de outros, sobre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506162-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506162-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069230/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23562151 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2069230 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL FERNANDO RAMOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

MICHAEL FERNANDO RAMOS DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de março de 2022, por volta das 17h10min, na Alameda Dino Bueno, 96, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16 (dezesseis) invólucros plásticos encerrando porção de material sólido particulado da substância cocaína, contendo aproximadamente 5,3g (cinco gramas e três decigramas) e 18 (dezoito) invólucros plásticos encerrando porção de material sólido petrificado da substância cocaína, vulgarmente conhecida como "crack", contendo aproximadamente 1,9g (uma grama e nove decigramas), além da quantia de R\$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) em notas fracionadas e moedas.

Segundo consta, guardas civis metropolitanos efetuavam policiamento fixo no projeto redenção, local de notória traficância de entorpecentes. Eles, então, avistaram MICHAEL em uma atitude suspeita e, então, deliberaram pela abordagem do indiciado. Efetuada a revista pessoal, encontraram entorpecentes e dinheiro. Indagado no local, confessou a traficância.

Convertida prisão em flagrante em preventiva as fls.70/74.

O réu foi citado (fls. 117) e apresentou defesa prévia as fls.121.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022 (fls.123/126).

Revoga prisão preventiva as fls.143/144.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. Após, procedeu-se ao interrogatório da ré.

Após, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição e desenvolveu teses subsidiárias. É o relatório.

Fundamento e Decido.

A denúncia é procedente.

Infere-se do conjunto probatório harmônico que, no dia 12 de março de 2022, por volta das 17h10min, na Alameda Dino Bueno, 96, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16(dezesesseis) invólucros plásticos encerrando porção de material sólido particulado da substância cocaína, contendo aproximadamente 5,3g (cinco gramas e três decigramas) e 18 (dezoito) invólucros plásticos encerrando porção de material sólido petrificado da substância cocaína, vulgarmente conhecida como "crack", contendo aproximadamente 1,9g (uma grama e nove decigramas), além da quantia de R\$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) em notas fracionadas e moedas.

Não obstante o boletim de ocorrência (fls.05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), exame toxicológico (fls. 157/159), a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 não restou confirmada pela prova oral produzida nos autos.

Não se ignora que, em que pese o acusado ter exercido seu direito de ficar em silêncio em solo policial, os guardas municipais disseram que, indagado no local dos fatos, ele teria admitido a traficância.

Contudo, em juízo, o acusado disse que trazia consigo as quantidades de drogas, mas não para tráfico; que a droga se destinava ao seu consumo próprio e de mais 4 rapazes; que tinha acabado de receber seu salário, pois trabalha como serralheiro; que, no bairro onde mora, trabalhava mais 4 rapazes; que foi comprar para uso comum deles; que o dinheiro que trazia consigo era o salário recebido por trabalhar como serralheiro; que os 4 rapazes também deram uma quantia de dinheiro para ele, para comprar as drogas; que tinha acabado de comprar as drogas na Cracolândia; que pagou R\$150,00 no crack e R\$130,00 na cocaína.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado não restou inverossímil diante do contexto probatório.

Ouvidos em juízo, o guarda Diego do Espirito Santo narrou que se recorda da ocorrência; que, na data dos fatos, notaram que o réu tinha volume na cintura; que o réu foi abordado diante da fundada suspeita; que solicitou-se que o réu parasse; que o réu tentou se evadir; que, com o auxílio da viatura, conseguiram abordá-lo; que foi encontrada sacola na cintura com os citados entorpecentes; que tinha dinheiro com o réu também, cerca de R\$1.500,00; que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas; que a sua função, como guarda municipal, é proteção dos agentes que trabalham na Cracolândia; que, por ser um local em que ocorrem muitos crimes, ao notar que o réu tinha volume na cintura, decidiram pela abordagem, porque entenderam que poderia tratar-se de uma arma, mas durante a abordagem pessoal, foi constatado que o volume tratava-se de drogas; que não questionou o réu acerca do que fazia com aquela quantia de drogas; que desconhece situação de que teria de conduzir outras pessoas que estavam ao redor ao DP também, já que o réu estava sob posse de entorpecentes e tentou evadir-se; que o réu não aparentava ser morador de rua; que o réu não aparentava estar sob efeito de drogas.

Já o Guarda Edison Marques da Costa, judicialmente, disse que estavam em patrulhamento; que o fluxo passou pelos guardas; que notaram volume na cintura do réu, momento que decidiram abordá-lo para certificar-se acerca do que era o volume; que, ao notar a aproximação dos guardas, o réu tentou evadir-se; que conseguiram detê-lo; que, na busca pessoal, foi constatado que o volume tratava-se de entorpecentes; que aparentemente o réu estava sob efeito de drogas; que foram apreendidas cocaína, crack e cerca de R\$1.500,00; que, no momento em que os policiais se movimentaram, as demais pessoas, que são usuárias, se aproximaram, então não conduziram mais ninguém, já que havia risco de virada do fluxo; que o réu admitiu que estava vendendo drogas; que não viram o réu vendendo drogas; que o réu foi abordado porque pensaram que o volume poderia tratar-se de uma arma. É verdade que os Guardas Municipais não estão impedidos de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, isto porque, seu depoimento, detém fé-pública.

Contudo, nenhum deles viu ato de traficância pelo acusado e a quantidade de entorpecente com ele apreendida, embora não inexpressiva, não é de todo incompatível com a alegação de se destinar a consumo próprio. Um dos guardas, ouvido em juízo, mencionou, inclusive, que o acusado parecia estar sob o efeito de drogas no momento da abordagem.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar, no máximo, a posse de entorpecentes para consumo pessoal. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas. Tampouco há de se falar em condenação pelo delito do art. 28 da mesma Lei, cuja inconstitucionalidade entendo de rigor declarar, incidentalmente, nesta oportunidade, a fim de considerar a conduta materialmente atípica (nesse sentido, doutrinariamente: BATISTA, Nilo. Punidos e mal pagos. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 66; BATISTA, Vera Malaguti. O Tribunal de Drogas e o Tigre de Papel. Revista Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 5, n. 12, pp. 191-192; CARVALHO, Salo de. A Política Criminal de Drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, passim; VALOIS, Luís Carlos. O Direito Penal da guerra às drogas. Belo Horizonte: D Plácido, 2016, passim).

Como esclarecimento preambular, importante pontuar que a análise será feita estritamente sob uma perspectiva técnica da dogmática jurídica penal-constitucional. Não se valorará se o consumo de drogas é bom ou ruim, tampouco se a criminalização do porte para consumo é uma política pública boa ou ruim, mas tão somente se é constitucional ou não. Ou seja, o que se buscará discutir é a constitucionalidade da repressão penal do consumidor de drogas, sem discutir a conveniência, ou não, de se autorizar o consumo ou de legalizar a sua comercialização.

Friso: debater os prejuízos e benefícios das drogas não são o escopo aqui. Tampouco se pretende abordar a efetividade empírica, ou não, da criminalização do consumo para sua redução, pois, conforme bem expõe Luís Greco em artigo, analisando a decisão do Tribunal Constitucional argentino sobre o tema: "O argumento da efetividade acima exposto apresenta fraquezas que, a rigor, se situam em dois planos: primeiramente na maneira como o argumento é desenvolvido na decisão, e, além disso, num plano mais fundamental, que diz respeito ao alcance geral de tais argumentos empíricos [...] O fato de que o consumo de drogas tenha crescido não significa que a proibição seja ineficaz, pois - ainda que se pressuponha que os dados levantados reflitam fielmente a realidade - não se pode saber se esses números não teriam subido ainda mais sem a proibição [...] O déficit, porém, é que esse argumento tampouco poderá obstar a uma nova mudança da jurisprudência, dessa vez em sentido inverso. Pense-se apenas na hipótese altamente plausível de que os futuros levantamentos dedados registrem um ulterior aumento do consumo de drogas. Aqui se vê um problema geral de qualquer argumento empírico: conclusões derivadas de argumentos empíricos dependem da situação do mundo e são portanto contingentes, porque não apenas o nosso conhecimento do mundo, mas o próprio mundo como objeto desse conhecimento está em constante mudança. Se se quiser recorrer ao empírico

para deduzir conclusões liberais, em especial limites ao poder do Estado, é de ter-se o cuidado de caracterizar esse argumento clara e expressamente como uma consideração adicional. Do contrário, não se fortalece, mas sim se acaba enfraquecendo o postulado limite ao poder estatal, uma vez que esse limite agora passa da situação contingente em que se encontra o mundo" (Posse de droga, privacidade, autonomia: reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional argentino sobre a inconstitucionalidade do tipo penal de posse de droga com a finalidade de próprio consumo. Rbccrim, São Paulo, v.18, n.87, nov/dez 2010).

Delimitados, portanto, os aspectos a não serem discutidos, tem-se que a definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MSn.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Por sua vez, diz o artigo 28 da Lei nº 11.343/06:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I - advertência verbal;

- multa.

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

Embora não se estabeleça pena de prisão, prevalece o entendimento de que ainda se trata de crime, tendo havido somente a despenalização da conduta com a Lei nº 11.343/06, mas não a descriminalização, até porque o próprio dispositivo legal faz uso da palavra "penas".

E, já antecipando os argumentos de que na verdade o tipo penal em pune o consumo de drogas, mas sim o porte para consumo, cabe destacar que, como o porte nesse caso se exaure no uso (até porque o porte destinado a terceiros configura tráfico), é evidente que o único destinatário da norma penal em questão é o usuário/consumidor. A defesa da constitucionalidade da norma em discussão costuma se fundar em três argumentos centrais: (i) a incriminação do consumidor visa a proteger a saúde do usuário; (ii) a criminalização do porte para consumo enfraquece o tráfico de drogas, pois, com a redução do consumo, conseqüentemente, reduz-se a venda, protegendo a saúde pública; (iii) contribui para a segurança pública, uma vez que o usuário contumaz é propenso à prática de crimes patrimoniais (ou outros) para financiar o consumo de drogas. Em suma, indica-se que a criminalização do consumo de drogas protege os seguintes bens jurídicos: (i) saúde individual; (ii) saúde

pública; (iii) o patrimônio, integridade física e vida de terceiros.

Passo a analisar pontualmente cada um desses argumentos.

A tutela da saúde individual do usuário é de longe o argumento mais frágil entre aqueles utilizados por quem se propõe a defender a constitucionalidade do delito. Isso porque, sob este prisma, a criminalização da conduta de portar droga para uso próprio, além de violar a autonomia e a autodeterminação do indivíduo, decorrências lógicas da dignidade humana, equivaleria a criminalizar a própria vítima. Daí a razão pela qual não se pune criminalmente qualquer outra forma de autolesão, sendo exemplo clássico o suicídio tentado. Como ensina ROXIN: "Impedir que as pessoas se despojem da própria dignidade não é problema do direito penal. Mesmo que se quisesse, por ex. considerar o suicídio um desprezo à própria dignidade o que eu não julgo correto este argumento não poderia ser trazido para fundamentar a punibilidade do suicídio tentado" (Estudos de direito penal. Tradução de Luis Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 40).

Poderia então se objetar, por exemplo, também sob a lógica da isonomia, sobre a legitimidade do Estado em obrigar o uso do cinto de segurança nos automóveis ou do capacete em motocicletas, cuja finalidade é proteger a integridade física do ocupante do veículo em caso de acidente. Embora tal objeção seja pertinente sob o ponto de vista da invasão na esfera de autodeterminação do indivíduo, deve-se lembrar que neste caso não se trata de norma de natureza penal (ultima ratio), mas sim administrativa, de modo que não há criminalização da conduta tal como ocorre no crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Aliás, aplicando essa mesma lógica, qualquer outra conduta prejudicial à saúde do próprio indivíduo, como a ingestão de álcool, tabaco, gordura, açúcar, sedentarismo ou até mesmo a prática de esportes radicais poderia ser criminalizada, em evidente invasão à esfera de autodeterminação do indivíduo.

O segundo argumento frequentemente trazido nos debates sobre a criminalização do porte para consumo diz respeito à inibição ao tráfico de drogas pela lógica de que o consumo alimenta o tráfico, o que se prestaria a proteger a saúde pública. Sobre esse argumento, o Professor Pierpaolo Cruz Bottini esclarece que "é preciso notar que o pragmatismo da eficácia não pode levar à restrição da liberdade do cidadão para combater comportamentos de outros, sobre os quais ele não tem domínio. Tratar-se-ia de uma afronta clara e evidente ao princípio da culpabilidade, pelo qual só é punível o comportamento controlável pelo autor, e da admissão de uma espécie de responsabilidade objetiva na aplicação da norma penal. Como ensina RUDOLPHI, apenas "sólo es apropiada para evitar o propiciar aquellas acciones corporales que le son posibles al autor individual, sobre la base de su capacidad de conducir su comportamiento externo"

Ora, o usuário de drogas não tem qualquer controle sobre o comportamento do traficante. E, ainda que se admita a possibilidade do usuário evitar o consumo de drogas – o que não é verdadeiro em inúmeros casos – impossível atribuir a ele o controle ou a condução do comportamento doloso do comerciante de drogas. A aplicação da pena com essa motivação seria punir alguém pelo ato do outro. Uma punição fundada na incapacidade do Estado de controlar o verdadeiro comportamento danoso.

Em suma, aplica-se a sanção no usuário diante da dificuldade de encontrar, investigar e condenar o verdadeiro culpado – no sentido dogmático – pela violação à saúde pública: o comerciante de produtos ilícitos. A Constituição Federal, ao determinar ao legislador o combate ao tráfico de drogas (CF, artigo 5º, XLIII), não conferiu carta branca para o uso de qualquer estratégia de política criminal, mas apenas aquelas que não conflitem com outros princípios do mesmo texto legal. A definição dos instrumentos para inibição do tráfico de drogas deve se pautar pelo respeito aos preceitos constitucionais, dentre os quais a já exposta dignidade humana, e a culpabilidade, que vedam a penalização de alguém pelo ato de outro, que não domina ou controla ([https://www.conjur.com.br/2015-abr-14/direito-defesa-descriminalizar-uso-drogas-questao-constitucional-parte#:~:text=Descriminalizar%20o%20uso%20de%20drogas%3A%20uma%20quest%C3%A3o%20constitucional%20\(Parte%202\)&text=Na%20%C3%BAltima%20coluna%2C%20iniciamos%20a,Gilmar%20Mendes\).](https://www.conjur.com.br/2015-abr-14/direito-defesa-descriminalizar-uso-drogas-questao-constitucional-parte#:~:text=Descriminalizar%20o%20uso%20de%20drogas%3A%20uma%20quest%C3%A3o%20constitucional%20(Parte%202)&text=Na%20%C3%BAltima%20coluna%2C%20iniciamos%20a,Gilmar%20Mendes).)

Ou seja, a criminalização do usuário de drogas por tal fundamento implicaria a sua instrumentalização para evitar ato de terceiro sobre o qual não tem controle, em violação ao princípio da culpabilidade do Direito Penal.

Seguindo essa linha de raciocínio, poder-se-ia objetar então que a mesma lógica deveria ser aplicada ao crime de receptação, pois nele se pune quem não praticou a subtração do bem. No caso da receptação, todavia, a punição do receptador não se presta unicamente a instrumentalizá-lo para evitar furtos e roubos. Na verdade, presta-se a punir quem, ciente da origem criminosa do produto (a título de dolo ou culpa), o adquire, agravando a subtração inicial por dificultar a retomada do bem pela vítima. Ou seja, não se pune a receptação apenas como instrumento para inibir furtos e roubos, que teriam menos estímulo caso não houvesse ninguém disposto a adquirir os produtos subtraídos, mas também porque a conduta do receptador, por si só, merece repressão penal em razão de agravar a lesão ao bem jurídico patrimônio. Da mesma forma que o consumidor não pode ser punido como forma de reprimir os atos do traficante, tampouco se pode presumir que o usuário cometerá um delito para obter a droga ou em razão de seu consumo. Como também ensina o Professor Pierpaolo Cruz Bottini, “o argumento de que a criminalização do porte para uso próprio de entorpecentes protege a segurança pública e bens jurídicos individuais como o patrimônio e a vida, em razão da periculosidade do viciado e sua potencialidade de cometimento de delitos em razão da droga – seja para obter recursos para sua aquisição, seja em razão da incapacidade de autocontrole decorrente de seu uso – também não procede em um modelo penal de culpabilidade, baseado no princípio da ofensividade. Da mesma forma que o consumidor não tem culpabilidade em relação ao traficante, também não a possui em referência aos seus próprios atos futuros, ao menos no momento em que porta ou usa o entorpecente. Não se pode presumir que o usuário cometerá um delito para obter a droga ou em razão de seu consumo. Tratar-se-ia de um exercício de futurologia, de uma presunção iure et de jure, inadmissível em direito penal. Não parece possível considerar o uso de drogas um ato preparatório punível relacionado ao cometimento de delitos dolosos posteriores, porque não existe uma linha causal necessária e constante, que permita a antecipação da punição.(...). Poder-se-ia fundamentar a punição do uso de drogas em um suposto desvalor do comportamento do usuário em se tornar voluntariamente incapaz de autocontrole (espécie de actio libera in causa), em situação propensa ao cometimento de crimes futuros. Porém, ainda que o Direito Penal admita a punição daquele que voluntariamente se tornou inimputável (CP, artigo 28, II), isso apenas ocorre quando praticado efetivamente um ato criminoso posterior. Assim, se alguém se embriaga e pratica um crime posterior – como lesões corporais – será punido por este, independente de sua capacidade de autocontrole no momento do ato. Mas não haverá sanção criminal pelo ato de se embriagar. Da mesma forma, não se justifica a punição do uso de drogas pela possível prática de crimes posteriores, o que não impede a punição por estes últimos, se cometidos, independente da imputabilidade do agente. Ademais, se admitidas tais razões para a criminalização do consumo de drogas, imperiosa seria sua extensão para o uso de outras substâncias também (ou mais) associadas à lesão de bens jurídicos, como o de álcool, uma vez que as estatísticas revelam sua íntima ligação com crimes dolosos e culposos (por exemplo, 65% dos acidentes de trânsito são causados por motoristas que dirigem sob efeito do álcool) ([https://www.conjur.com.br/2015-abr-14/direito-defesa-descriminalizar-uso-drogas-questao-constitucional-parte#:~:text=Descriminalizar%20o%20uso%20de%20drogas%3A%20uma%20quest%C3%A3o%20constitucional%20\(Parte%202\)&text=Na%20C3%BA%20coluna%2C%20iniciamos%20a,Gilmar%20Mendes\)](https://www.conjur.com.br/2015-abr-14/direito-defesa-descriminalizar-uso-drogas-questao-constitucional-parte#:~:text=Descriminalizar%20o%20uso%20de%20drogas%3A%20uma%20quest%C3%A3o%20constitucional%20(Parte%202)&text=Na%20C3%BA%20coluna%2C%20iniciamos%20a,Gilmar%20Mendes))).

Quanto a esse argumento, seria possível objetar que, no crime de embriaguez ao volante, por exemplo, a criminalização da conduta também se dá pelo que pode vir a decorrer dela (acidente com lesão ou morte), e não pelo que já ocorreu. Ou seja, também haveria uma antecipação da tutela penal. Trata-se, em linguagem penal, dos chamados crimes de perigo (em contraposição aos crimes de dano), destinados a coibir condutas que exponham a risco (crimes de perigo concreto) ou tenham potencial para expor a risco (crimes de perigo abstrato) o bem jurídico tutelado pela norma penal mesmo antes que qualquer dano ocorra (e mesmo que sequer venha a ocorrer). É preciso, todavia, que a relação de causalidade entre a conduta e os potenciais

resultados lesivos tenha um mínimo de consistência, de modo que não se caia no mero campo da especulação ou da futurologia, como bem esclareceu o Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RE nº 635659/SP:

"Assim, os tipos de perigo abstrato descrevem ações que, segundo a experiência, produzem efetiva lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico digno de proteção penal, ainda que concretamente essa lesão ou esse perigo de lesão não venham a ocorrer. O legislador formula, dessa forma, uma presunção absoluta a respeito da periculosidade de determinada conduta em relação ao bem jurídico que pretende proteger. O perigo, nesse sentido, não é concreto, mas apenas abstrato. Não é necessário, portanto, que, no caso concreto, a lesão ou o perigo de lesão venham a se efetivar. O delito estará consumado com a mera conduta descrita na lei penal. Cabe observar que a definição de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato acaba se mostrando, muitas vezes, como alternativa mais eficaz para a proteção de bens de caráter difuso ou coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde pública, entre outros, o que permite ao legislador optar por um direito penal nitidamente preventivo. Portanto, pode o legislador, dentro de suas margens de avaliação e de decisão, definir as medidas mais adequadas e necessárias à efetiva proteção de bens jurídicos dessa natureza. Por outro lado, não é difícil entender as características e os contornos da delicada relação entre os delitos de perigo abstrato e os princípios da lesividade ou ofensividade, os quais, por sua vez, estão intrinsecamente relacionados com o princípio da proporcionalidade. A atividade legislativa de produção de tipos de perigo abstrato deve, por isso, ser objeto de rígida fiscalização a respeito de sua constitucionalidade".

No caso da embriaguez ao volante, a criminalização se justifica porque não se incrimina apenas a conduta de se embriagar (o que seria análogo ao art. 28 da Lei de Drogas), mas sim a conduta de, estando embriagado (com capacidade psicomotor alterada), conduzir veículo automotor, conduta essa que coloca em risco a incolumidade de terceiros, causando boa parte dos acidentes de trânsito todos os anos no país.

Assim, o que se constata é que, no caso da embriaguez ao volante (e em outros crimes de perigo abstrato), há uma relação mais próxima entre a conduta incriminada e o risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que não ocorre no delito do art. 28 da Lei de Drogas, no qual, entre a conduta de portar droga para consumo pessoal e vir a praticar delitos futuros para financiar eventual dependência química (agressões e extorsões a familiares, furtos e roubos e outros crimes patrimoniais em geral), há um longo e incerto caminho.

Destaco entendimento da C. 6ª Câmara Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em acórdão da lavra do Des. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES, considerou inconstitucional o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Confira-se:

"O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil." (TJSP Apelação Criminal nº 01113563.3/0-0000-000, 6ª Câmara Dir.Criminal, j. 31/03/2008). Pertinente a menção ao princípio da igualdade, eis que, de fato, há flagrante "distinção de tratamento penal (drogas ilícitas) e não-penal (drogas lícitas) para usuários de diferentes substâncias, tendo ambas potencialidade de determinar dependência física e psíquica" (Salo de Carvalho, A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático, Editora Lumen Juris, RJ, 2007, p. 253). Ademais, da fundamentação do v. acórdão, extrai-se que transformar aquele que tem a droga apenas e tão-somente para uso próprio em agente causador de perigo à incolumidade pública, como se fosse um potencial traficante, implica em frontal violação do princípio da ofensividade, dogma garantista previsto no art. 5º, XXXV,

da CF.

Ora, o princípio da lesividade exige que a ofensa ao bem jurídico caracterizadora do conteúdo material do injusto dê-se de modo transcendente ao sujeito ativo do crime. Contrariamente, como repetido ao longo da presente decisão, a conduta do agente que porta drogas para seu consumo invade tão somente a sua esfera pessoal. Portanto, do ponto de vista técnico-penal, inexiste periculosidade, ofensividade ou lesividade no consumo de entorpecentes, e consequentemente não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica.

Num Estado Social e Democrático de Direito, a intervenção punitiva somente se justifica nas condutas transcendentais aos demais, ou seja, que atinjam as esferas de liberdade alheias, sendo contrário ao princípio da ofensividade o castigo de uma conduta imoral, antiética ou antiestética que não invada a liberdade alheia. Com efeito, falta lesividade ao tipo penal e sem ela não atua o Direito Penal, pois, na lúcida observação de Claus Roxin, "o legislador, mandatário do povo, tem sua tarefa limitada à proteção do indivíduo dos ataques dos outros e a assegurar uma vida mais livre possível e de maior bem-estar possível, e nada tem a ver com tal tarefa tutelar moralmente cidadãos adultos contra sua vontade" (Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Trad. cast. Barcelona, 1989, p. 22).

Nessa medida, o art. 28 da Lei de Tóxicos fere o princípio da alteridade, mandado de otimização o qual impede a incriminação de conduta que prejudica somente ao agente, ou seja, proíbe a incriminação de ações internas e que só digam respeito ao próprio indivíduo. Neste sentido, se as ações do indivíduo limitam-se apenas ao seu interior, não transcendendo ao ambiente externo, e por consequência não ferindo, prejudicando ou lesando interesses de outrem, impossível a aplicação do "jus puniendi" (direito de punir pelo Estado).

Em julgamento do RE 635.659, alguns ministros do STF já se manifestaram pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei Antidrogas. Na discussão em andamento no Supremo, o Ministro Edson Fachin asseverou:

(...) A interpretação do Direito Penal à luz da Carta da República tem sentido a partir de duas premissas básicas: a diferenciação entre penas e medidas de segurança, e a exigência de expressa previsão constitucional, para justificar a limitação de direitos fundamentais. A primeira premissa indica que, em situações excepcionabilíssimas, é possível atribuir a qualidade de perigo a determinada pessoa. Por isso, exceto nas situações em que o desenvolvimento bio-psico-social afaste a culpabilidade, a separação entre penas e medidas de segurança jamais autorizaria fazer recair sobre a pessoa do agente o juízo de condenações. Já neste ponto é possível antever que a incriminação da drogadição situa-se na tênue delimitação entre o Direito Penal do autor e o do fato. Com efeito, a posse para uso pessoal, embora tipifique a ação, incide sobre conduta que, não raro, é condição essencial da pessoa, e a vetor constitucional que não autoriza a penalização da personalidade. No que tange às limitações dos direitos fundamentais, é preciso que eventual restrição encontre fundamentação constitucional. Nessa diretriz, alberga-se o princípio da tipicidade, a exigir reserva de lei para normas penais.

Considerando que a tipicidade decorre da teoria sobre os direitos fundamentais, ao legislador não compete apenas observar a reserva de lei para tipificar determinada conduta, como também deve demonstrar que pela incriminação outro direito fundamental será protegido. A doutrina costuma indicar que a sede do princípio da ofensividade como parâmetro de controle de constitucionalidade reside no art. 98, I, da Constituição da República. Embora a referência tópica possa constar desse dispositivo, o conteúdo do princípio decorre, de um lado, da opção constitucional e legal por um Direito Penal orientado por fatos; e, de outro, da impossibilidade de se criminalizar condutas que não atinjam um fundamento constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, é correto afirmar que o princípio da ofensividade tem assento constitucional e serve de parâmetro para o controle da atividade do Legislativo. Esse controle não incide, entretanto, indistintamente sobre todas as normas penais, nem sobre os objetivos e motivações invocados para edição da norma, pois, em tais circunstâncias, seria preciso recorrer-se a argumentos consequencialistas, para afastar a prerrogativa de avaliação feita pelo

Legislativo. O princípio da ofensividade permite, de fato, a limitação do próprio direito, mas não autoriza que se oponham argumentos utilitários à validade normativa. Essa tarefa tem ainda maior importância se o reconhecimento da extensão dos bens jurídicos e da consequente proteção estatal for medida em relação à eventual restrição da liberdade. Nesse sentido, caberia à teoria do bem jurídico identificar quais bens podem justificar a restrição à liberdade. Não se trata, contudo, de afastar a priori qualquer pretensão de permitir ao Estado perseguir fins morais. Ao contrário, inexistente um princípio que delimite a esse ponto a atividade estatal regulatória. É preciso registrar, neste particular, que a possibilidade de se buscar fins morais não é descontextualizada: apenas em sociedades em que haja o respeito à autonomia dos cidadãos, garantindo-se-lhes um amplo espectro de opções valorosas (RAZ, Joseph. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1986), é que seria possível falar em uma larga margem de validação para estabelecer fins morais. O ponto de partida para se delimitar o campo de restrição à autonomia parece estar no princípio da ofensividade: somente havendo dano efetivo, porquanto haveria, por conseguinte, uma interferência na autonomia das outras pessoas, é que se pode legitimar a coerção. A sanção penal é, assim, tão-só uma das formas de se proteger os bens jurídicos. Consubstanciando a mais grave restrição na autonomia dos cidadãos, cumpre, portanto, avaliar se ela é adequadamente posta. E é aqui que tem assento a proporcionalidade. Especificamente em relação à coerção penal, poder-se-ia apontar, na linha do que indica Claus Roxin, serem ilegítimas as incriminações de: motivações ideológicas; autolesão; tabus; finsextrapenais; e abstrações incapazes de constituir bens jurídicos (ROXIN, Claus. *Es la protección de los bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?* In: *La teoría del bien jurídico. Fundamentos de legitimación del derecho penal o juego de laboratorios dogmáticos?* Roland Hefendehl (ed.). Barcelona: Marcial Pons, 2007). Essas considerações parecem indicar que, em vista da ofensa a um bem individual, não se pode dar ensejo à criminalização. Esse norte tem sentido especialmente para o adicto, usuário dependente de droga; impende ajudar o usuário que queira se livrar do poder criminoso da dependência. Frise-se, relativamente a esta inferência, que não se visa inviabilizar a atividade regulatória do Estado, nem mesmo a de imposição de sanções, mas a afastar que a regulação seja feita por meio da coerção penal como primeiro antídoto. (...)

Em seu voto, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim ponderou: (...)

Na valoração da importância de determinado interesse coletivo como justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do dano potencial associado à conduta objeto de incriminação. Em outras palavras, há que se verificar em que medida os riscos a que sujeitos os interesses coletivos podem justificar a conversão destes em objeto de proteção pelo direito penal. Conforme observa PUIG, o Estado Social não pode desconhecer, [na definição de crimes de perigo abstrato], a significação que, por si mesma, implica a extensão social de um determinado interesse e tampouco há de prescindir da exigência de um mínimo de repercussão do interesse coletivo em relação a cada indivíduo. Acredita o autor ser essa a via adequada se se pretende evitar a hipertrofia do direito penal (PUIG, Santiago Mir, "Concepto de Bien Jurídico-Penal como Límite del Ius Puniedi", *Estudios de Derecho Penal, Processual e Criminologia em Homenagem ao Prof. Dr. Kurt Maldlener*, coordenadores Adhemar Ferreira Maciel et alii. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciário, 2014). E exemplifica justamente com o direito à saúde pública. Não cabe negar, afirma o autor, que a saúde pública é um interesse coletivo que afeta cada indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade individual para que se possa justificar a intervenção do direito penal. Até agora não se tem afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco afetam suficientemente a saúde pública a ponto de legitimar a criminalização de sua venda e consumo. Em relação ao tabaco, observa que a proteção da ordem pública coletiva tem sido alcançada com o incremento da proibição de seu consumo em lugares públicos, porém por meio de medidas administrativas. O mesmo raciocínio, ainda segundo PUIG, aplica-se em relação às drogas. Sustenta ser preciso diferenciar as drogas quanto a seus distintos efeitos em relação a cada indivíduo. Além disso, há que se ter em conta que a lesividade individual vem, neste caso, acompanhada do

consentimento da vítima. Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas art. 4º da Lei 11.343/06 é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas. Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade. Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social. A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal. Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional. (...)

Neste sentido, resta claro, inclusive, que o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos viola não só o princípio da alteridade, mas também viola o direito à privacidade e intimidade, os quais devem ensejar ações negativas de abstenção do Estado, nos termos da Carta Magna. Oportuno enfatizar que, até mesmo ao tempo da Lei 6368/76 havia outros entendimentos jurisprudenciais no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que consideravam atípica a conduta do porte de entorpecente, conforme pode se verificar a seguir:

O legislador sanciona a aquisição, a guarda e o porte do entorpecente para uso próprio, entendendo que 'o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo porque é fator decisivo na difusão do tóxico. No entanto, a partir do momento em que a consome, lesa a si próprio e sua conduta não representa mais um perigo social' (Ap. 168.697, TACRIM).

Em suma, a lei se justifica na promoção do bem comum, objetivando impedir condutas danosas ou de risco à sociedade. Logo, a lei não deve atuar se a conduta por ela visada não ameaçar a Coletividade. Por esta razão, aliás, a lei não proíbe a auto-lesão ou o consumo de substâncias lícitas a menos que tais condutas atinjam ou possam atingir terceiros (por exemplo, no caso de mutilação com vistas a fraudar seguro ou de direção de veículo com concentração etílica incompatível com esta prática).

A lei não pode ser utilizada com a finalidade de se impor uma forma de Pensamento. Em uma sociedade plural, como preconizado no Preâmbulo da Constituição Federal, pessoas têm convicções diferentes, encontrando bem-estar de maneiras distintas e arcando com as consequências pessoais de tal ou qual decisão. Nesta sociedade, o Estado só age para evitar que a conduta de uma pessoa interfira na vida de outra, garantindo o exercício harmônico das liberdades humanas. Tomado em si mesmo, o uso de drogas nada gera além da alteração de consciência, obtida também por meio de substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco. Não há coerência na permissão de umas e proibição de outras. Tem-se, daí, a intenção estatal de impor um padrão de conduta, decorrente de uma suposta maioria, tratando como crime (com todas as consequências seríssimas decorrentes, incluindo a inclusão de maus antecedentes) aquilo que, de há muito se diz, deveria ser tratado como questão de Saúde Pública.

Como já demonstrado, mostra-se inválido, juridicamente, o argumento corrente de que a criminalização se justificaria no combate ao tráfico. Embora com alguma lógica cartesiana, a afirmação esbarra no princípio de que, em direito penal, as condutas devem ser individualizadas, não se punindo aquele que não causou, direta ou indiretamente, o perigo ou o dano. Por tal razão, apenas o traficante deve ser

punido pelo mal que gera: a distribuição das drogas sem nenhuma preocupação com as consequências que sua disseminação causará.

Não se cuida, aqui, de apologia, nem sequer de aprovação. Longe disso. Trata-se, como não poderia deixar de ser, unicamente de interpretação jurídica, segundo a qual o Estado só pode restringir o âmbito da atuação humana se a conduta pretendida, pelo menos abstratamente - mas nunca especulativamente -, causar ou puder causar danos ou riscos relevantes à sociedade. É arbitrária, portanto, a punição de alguém que apenas desejou ingerir algo, causando mal unicamente a si próprio.

A criminalização do uso de drogas, ou do porte para o uso delas, configura restrição indevida da liberdade. Procura-se, com isto, marginalizar pessoas cujos hábitos são condenados por parte da população, o que se afigura inadmissível, conforme o artigo 3º, IV, da Constituição Federal, dispositivo que veda todas as formas de discriminação. Ademais, os valores humanos da intimidade e da vida privada são direitos individuais conexos ao próprio direito à vida (também assegurado pelo art. 5º da CRFB, em seu caput).

Destarte, é indubitável a necessidade de constatar-se a (in)constitucionalidade da criminalização do consumo de drogas no Brasil frente ao princípio constitucional da liberdade individual, que é e deve ser (no plano normativo) a primeira e mais importante garantia do ser humano, bem como frente ao princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada do indivíduo.

Soma-se a tudo isso o argumento de que, com a despenalização da figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06, possível a conclusão de que a conduta do consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, já que a sanção para tal conduta se tornou tão ínfima, com natureza próxima a um direito penal promocional. Ora, pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal deve intervir nas relações sociais apenas quando determinada conduta atinja o bem jurídico de modo intolerável e, para que consolide como um adequado instrumento de tutela aos bens jurídicos mais relevantes para o sistema, promovendo efetivamente a prevenção delitiva geral e especial, a intervenção penal não pode ser meramente simbólica.

Não é o que se verifica no caso do art. 28, eis que a sanção para tal conduta é inofensiva a ponto de quase banalizar o Direito Penal, o qual não deve cuidar de condutas bagatelares ou ínfimas, mas tão somente aquelas que realmente lesionem o bem jurídico tutelado.

Em linha semelhante linha de pensamento, ressaltem-se decisões atuais do STJ, que não mais consideram as condenações pelo disposto no artigo 28 da Lei Antidrogas para fins de reincidência: as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerandodesproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anteriordo art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Em suma, nos deparamos com um crime "despenalizado", que enseja no máximo condenações que não possibilitam a prisão ou outras penas típicas do direito penal, incapaz de gerar reincidência, desfeito à alteridade, tudo a corroborar com a conclusão de que a conduta está equivocadamente recebendo tratamento pelo Direito Penal quando pertenceria, na verdade, a outros ramos do pensamento e comportamento humanos.

No mais, a quantidade de entorpecentes encontrada com o réu foi ínfima, de modo que, em argumento de reforço, seria ainda passível a incidência do princípio da insignificância, a tornar atípica a conduta, também sob este ponto de vista.

Destaco à luz de referido postulado os seguintes julgados:

Apelação. Porte de entorpecentes para consumo próprio. Condenação. Recurso exclusivo da defesa. Acusado flagrado em poder de apenas um cigarro de maconha,

parcialmente consumido, com peso de dois gramas. Atipicidade material da conduta. Aplicação excepcional do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer perigo de lesão à saúde pública. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Absolvição que se impõe. Reforma da sentença. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0003908-96.2015.8.26.0048; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2015; Data de Registro: 04/04/2019).

Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal).

Por essas razões, DECLARO incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e ABSOLVO o réu da imputação pelos art. 28 e 33 do CPP, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP.

Tendo em vista absolvição, custas na forma da lei
P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA